

1501668-22.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501668-22.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501668-22.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2136995/2021 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 18022832 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

3141/21/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2136995 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

3141/21/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS FERREIRA DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

MARCOS FERREIRA DE FREITAS, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 19 de maio de 2021, por volta de 19h52min, na Avenida M 29, nº 1014, com a Rua M 8, Jardim Chervezon, nesta Comarca, agindo com o concurso e com identidade de propósitos com o adolescente Charles Deoclecio Dos Santos Del Pozzo, que envolvia na prática clandestina, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia

consigo 43 (quarenta e três) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido de 10,5 gramas, bem como 48 (quarenta e oito) invólucros plásticos contendo a substância entorpecente denominada tetrahidrocannabinol, totalizando peso líquido de 89,1 gramas, concorrendo, de qualquer modo, para que o adolescente trouxesse outros 15 (quinze) invólucros plásticos contendo a mesma substância entorpecente denominada tetrahidrocannabinol, totalizando peso líquido de 26,9 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23 e laudo de constatação preliminar de fls. 28/31, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 82/84). Regularmente notificado (fls. 131), seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado (fls. 135/142), sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 23 de setembro de 2021 (fls. 154/161).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 184/185), seguindo-se o interrogatório do acusado (fls. 184/185).

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a parcial procedência da ação penal para condenar o acusado tão somente como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, afastando-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, do mesmo Diploma Legal, com fixação da pena base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com imposição de regime prisional inicial menos gravoso que o fechado. Por fim, pugnou pelo pedimento da quantia em dinheiro apreendida, nos termos do que disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 60 da Lei nº 11.343/06 (fls. 184/185, 207). Já a ilustre Defensora Pública, preliminarmente, requereu a conversão do julgamento em diligência, que resultou na juntada do documento de fls. 166. Sustentou, ademais, estar a prova da materialidade delitiva prejudicada, já que originada de apreensão ilícita do entorpecente, uma vez que realizada por Guardas Civis Municipais, os quais não possuem atribuições para realizar diligências como aquelas efetuadas na ocasião, configurando atuação ilícita, inclusive em afronta aos artigos 144 da Constituição Federal, Lei Complementar 13.022/2014, artigo 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, a ensejar a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, sustentou insuficiente a prova produzida, requerendo a absolvição do acusado, aqui nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Assim não se entendendo, pugnou pela desclassificação do delito atribuído inicialmente ao acusado para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Em caso de condenação pela imputação inicial, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, com o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, fixando-se a pena a quem do mínimo legal; o afastamento da majorante articulada na denúncia, observando-se o princípio da congruência neste ponto, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional inicial aberto, a restituição do dinheiro apreendido, além da concessão de liberdade provisória -- que foi efetivamente concedida por este Juízo, com expedição de alvará de soltura (fls. 184/185, 210).

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede em parte a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, assim porque, agindo com o concurso e identidade de propósitos com um adolescente, que estaria envolvendo na prática clandestina, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo o entorpecente indicado na denúncia e concorria, de qualquer modo, para que aquele adolescente trouxesse outra quantidade de substância ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no auto de exibição e apreensão de fls. 23 e laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 95/96, com resultado positivo para cocaína e para

tetrahydrocanabiol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha. Sustenta-se prejudicada a materialidade delitativa, diante das diligências realizadas, já que a Guarda Civil Municipal não reuniria atribuições para a abordagem, à vista do disposto no artigo 144, §8º, da Constituição Federal. Entretanto, consta que Guardas Civis Municipais estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado e o adolescente, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, os quais se mostraram apreensivos e, com a aproximação da viatura, tentaram empreender fuga, em situação que expunha o estado flagrancial, autorizando a abordagem (cf. Art. 301, CPP), que resultou efetivamente na apreensão de entorpecentes.

Não se ignora a controvérsia que marca os limites da ação da Guarda Municipal, importante estrutura que atua nos Municípios em proveito da segurança pública, notadamente em ambiente de intensa criminalidade. Não por outro motivo se editou a Lei n. 13.044/2014 com o objetivo de regulamentar a extensão do disposto no artigo 144, §8º, da Constituição Federal, de modo a incorporá-la ao sistema de atuação dos organismos que atuam em favor da segurança pública, embora objeto de ação direta de inconstitucionalidade, que não se entrevê por aqui em caráter incidental.

E a situação, no caso, dentro das competências estabelecidas pela referida Lei Federal, diante do comportamento do acusado e do adolescente, tentando empreender fuga, decorre da experiência comum, do id quod plerumque accidit, que tal comportamento se ajusta a ocorrência de empreita delitativa, evidenciando estado flagrancial, a autorizar a abordagem, seguida da busca pessoal, que resultou efetivamente na apreensão do entorpecente.

A propósito: HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...] (HC 421.954/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018) Grifos Nossos.

Assim, fica afastada a alegação de ter restado comprometida a materialidade delitativa.

Controverte-se sobre a posse do entorpecente apreendido.

Ouvido em juízo o acusado negou a prática delitativa e a posse do entorpecente. Relatou que foi até o local para adquirir droga para o próprio consumo e que, quando abordado, os Policiais já tinham apreendido o adolescente, que assumiu a propriedade do entorpecente encontrado em um terreno baldio, nas imediações. Acrescentou, por fim, que já respondeu a processo por tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 184/185).

Todavia, a versão deduzida pelo acusado, foi contrariada pela prova produzida. De fato, os Guardas Civis Municipais, Dhieimison e Leandro, que participaram das diligências que culminaram na apreensão do entorpecente, reiterando o que inicialmente exposto, afirmaram que estavam em patrulhamento por local conhecido como ponto de tráfico de entorpecente, quando avistaram o acusado e o adolescente, ambos em seguida tentando fuga. Por este motivo, foi realizada a abordagem e, em busca pessoal, foram apreendidos, sob as vestes íntimas do acusado, 48 (quarenta e oito) porções de maconha, 43 (quarenta e três) microtubos de cocaína, além da quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco) em dinheiro. Acrescentaram que com o adolescente foram também localizadas 15 (quinze) porções de maconha, ambos admitindo que estavam realizando o comércio ilícito naquela localidade, e que dinheiro advinha daquela atividade. Informaram, por fim, que efetivaram buscas nas imediações juntamente a um cão de faro, mas nada foi localizado (fls. 184/185). Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos Guardas Civis Municipais envolvidos

na diligência.

A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829). Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu). Ademais, além da presunção de idoneidade de que gozam os testemunhos, não se mostra crível que os Guardas Municipais estivessem portando a expressiva quantidade de entorpecentes, e de naturezas diversas, tão somente para incriminar o acusado. Deste modo, os elementos probatórios produzidos permitem seguro juízo de convicção sobre a posse do entorpecente, bem como sobre sua destinação mercantil, não apenas em função da quantidade apreendida, como também em razão das circunstâncias relacionadas à apreensão (local de venda, diversidade de entorpecentes, embalagem em unidades e confissão informal), ficando afastado, portanto, o reclamo de desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Contudo, e isto foi reconhecido pelo próprio Ministério Público, não há lugar para a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, assim porque não há indicação segura de que estivesse o acusado envolvendo o adolescente na prática delitiva ou se agia com autonomia.

Por fim, deixa-se de impor a pena de perdimento da quantia em dinheiro apreendida em poder do acusado, porque não há prova bastante de que efetivamente decorrente da atividade ilícita, devendo ser oportunamente restituída.

Isto considerando, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de considerar a circunstância atenuante da menoridade relativa, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ).

Entretanto, deve pena-base cominada ser reduzida em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito.

O acusado é primário, não ostenta condenação criminal anterior, não havendo indicação suficiente, por ocasião dos fatos, de que estivesse já dedicado à atividade criminosa, de tal modo que deve a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do

tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda. Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, e artigos 44 e 46, ambos do Código Penal, CONDENO o acusado MARCOS FERREIRA DE FREITAS à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em

execução, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Oportunamente, promova-se a restituição dos valores apreendidos e o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA